

1501703-61.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... duas condenações anteriores também por tráfico.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501703-61.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501703-61.2022.8.26.0537 Controle nº 1254/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO DE SOUSA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

EVANDRO DE SOUSA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 12:00 horas, no interior da residência situada na Rua General Bertoldo Klinger, n.º 18, Bairro Taboão, adquiriu, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 73/76), tendo sido reapreciada, e mantida, por decisão de 20.10.22 (fls. 188).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 182/183), sendo recebida a denúncia em 20.10.22 (fls. 187). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de

drogas, a agravante da dupla reincidência específica, fixação de regime fechado, que seja afastada a aplicação do art. 33, § 4.º por ser reincidente.

O Defensor Público requereu a nulidade das provas produzidas em juízo em razão do ingresso no imóvel por autorização de terceiro ou caso de eventual condenação, que seja compensada a reincidência com a confissão extrajudicial, a detração e a fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Iniciamente, não há que se acolher o pedido de nulidade das provas pelo ingresso dos policiais na residência, posto que houve autorização do proprietário do imóvel (locador), o qual inclusive confirmou isso na fase policial, o que também foi informado pelos policiais nas duas fases. Ademais, havia motivos para o ingresso dos policiais, uma vez que o réu saiu de tal local, dispensou uma sacola que continha drogas e se evadiu. Somente após isso, os policiais ingressaram na residência da qual o réu saiu, que havia denúncia ser a "Casa Bomba" e com autorização do dono da mesma (locador). O réu não poderia autorizar o ingresso já que se evadiu.

Ademais, "ad argumentandum", ainda que se considerasse que essa prova é ilícita, o réu anteriormente dispensou uma sacola contendo drogas para abastecer a "Loja 5", o que já caracteriza o tráfico, ainda mais que confessou na fase extrajudicial e é duplamente reincidente específico.

Na fase policial (fls. 10), o acusado confessou a prática do crime. Disse que alugou o imóvel para armazenar drogas e abastecer alguns pontos de venda na região. Falou que pediu à mulher que alugasse o imóvel para ele, pois não tinha documentação para tanto, mas não a informou para qual finalidade utilizaria o local. Relatou que os policiais tentaram abordá-lo quando deixou o local ("Casa Bomba"), levando consigo certa quantidade de drogas para abastecer a "Loja 5", mas conseguiu se evadir e dispensar uma bolsa com entorpecentes. Narrou que para fugir pulou o muro de um terreno baldio, contíguo a um prédio residencial, e se feriu nas mãos em uma serpentina (ofendículo). Narrou que pediu ajuda a uma pessoa que estava no local, mas esta não quis ajudá-lo. Então, tentou se esconder no prédio, onde minutos depois foi detido por policiais militares e conduzido ao distrito policial. Negou ter tentado invadir a residência da testemunha. Afirmou que as drogas apreendidas no imóvel lhe pertenciam, assim como o documento. Não foi agredido por nenhum policial.

Em juízo, negou ter praticado o crime, alegando que é tatuador e estava em Diadema para fazer uma tatuagem na casa do cliente, sendo abordado quando passava pelo local. Não conhece a residência onde foram achadas as drogas, nem Caroline. Mora com a mãe em São Paulo, no bairro Parque Bristol. Narrou que saiu um homem de um Palio, apontando a arma para ele, por isso se evadiu, deixando cair a sacola com materiais de tatuagem e sua carteira de trabalho. Não conhecia os policiais. Os policiais civis, na fase extrajudicial (fls. 03 e 05), disseram que foram até o local dos fatos para cumprir ordem de serviço, que informava que o imóvel localizado naquele era utilizado como "Casa Bomba". Relataram que após algum tempo viram o réu deixando a residência e tentaram abordá-lo, porém este se evadiu, deixando a porta da casa aberta, e dispensou um pacote pela via pública. Afirmaram que localizaram drogas no pacote dispensado pelo réu. Narraram que retornavam ao imóvel e que neste compareceu José Belmiro Filho (sic), que se identificou como proprietário daquele, exibiu um contrato de locação em nome de Caroline Victorino Justiniano e autorizou a entrada deles no local. Afirmaram que na parte superior da casa localizaram diversas drogas (cocaína, maconha e "crack"). Falaram que em contra partes da casa localizaram uma conta da luz em nome do proprietário, anotações compatíveis com "contabilidade do tráfico", 4 telefones celulares e uma carteira de trabalho (CTPS) em nome do réu. Informaram que enquanto aguardavam a Perícia no local, compareceu neste uma mulher que afirmou ser prima do réu e que havia ido até a residência buscar roupas para este, pois estava preso no 5.º D.P de São Bernardo do Campo. Informaram que após a realização dos exames periciais foram até a referida delegacia e reconheceram o réu como o mesmo homem que havia se evadido após deixar a "Casa Bomba".

André (policial civil), em juízo, informou que tinha denúncia anônima de tráfico, viram o réu saindo da casa, o qual jogou uma sacola e se evadiu. Foram até a residência, o proprietário permitiu o ingresso e acharam drogas. Ficaram sabendo que o réu se machucou durante a fuga e foi detido pela PM por ter entrado em um condomínio. O réu falou que alugou a casa, junto com sua companheira, e estava usando para fazer o abastecimento de drogas para a loja 5. As drogas estavam divididas em porções (mais de 1000 de cocaína, 500 de "crack" e 500 de maconha). Na sacola dispensada pelo réu havia drogas. Informou que na residência tinha a carteira profissional do réu, havia uma guarda-roupas com bastantes roupas. O proprietário apresentou um contrato de locação cuja locatária era Caroline e permitiu a entrada no imóvel. Reconheceu o réu como sendo o homem que se evadiu da "Casa Bomba".

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial José Antônio. Reconheceu o réu como sendo o homem que se evadiu da Casa Bomba.

Os policiais militares, na fase extrajudicial (fls. 07/08), disseram que foram acionados, via COPOM, para atender ocorrência de "furto a transeunte pela via". Relataram que no local da suposta ocorrência foram informados por moradores do edifício que um homem havia invadido o local e se cortado nas grades de proteção (ofendículos) ao pular o muro. Narraram que foram seguindo pingos de sangue até que se depararam com o réu no 15.º andar do prédio, quando este iria bater à porta de um dos apartamentos, e o detiveram. Informaram que conduziram o réu e uma testemunha para o 5.º D.P de São Bernardo do Campo, onde foram informados de que ele havia acabado de fugir à abordagem de policiais do 3.º D.P de Diadema. Disseram que, após a anuência da autoridade policial do 5.º D.P de São Bernardo do Campo, conduziram o réu até o 3.º D.P de Diadema.

Bruno (policial militar), em juízo, disse foram até o local para verificar uma denúncia de invasão de domicílio e abordaram o réu. Os policiais civis apareceram no D.P informando que o réu se evadiu da "Casa Bomba" e que nesta acharam as drogas.

José Belarmino, na fase extrajudicial (fls. 09), disse que locou seu imóvel para uma mulher que se identificou como Caroline Victorino Justiniano, por meio de contrato de locação assinado por ambos. Falou que Caroline propôs pagar R\$ 1.000,00 adiantados para a locação e foi até a casa dele no mesmo dia para entregar o valor. Afirmou que autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, acompanhou as buscas e presenciou o momento em que localizaram os entorpecentes apreendidos. Na delegacia reconheceu Caroline Victorino Justiniano, por fotografia, como a mulher que locou seu imóvel (fls. 61). Reconheceu o réu, por meio da fotografia da CTPS apreendida, como sendo o homem que costumava frequentar a residência (fls. 60).

O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

Além disso, o fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). A grande quantidade (fls. 22 - 506 porções de maconha, 883 invólucros de cocaína e 1119 pedras de "crack") e variedade (maconha, cocaína e "crack") de drogas apreendidas (na sacola que dispensou e na "Casa Bomba"), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, bem como a confissão extrajudicial e informal, além da apreensão da Carteira de Trabalho (fls. 21) do réu na "Casa Bomba" e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade e variedade se não fosse traficante.

A negativa judicial do réu está isolada, posto que alegou que estava trabalhando como tatuador e com materiais para tatuagem, mas nada provou como lhe incumbia nos termos do art 156 do CPP e sua versão foi desmentida pelos policiais no sentido de que saiu da casa, dispensou a sacola com drogas, se evadiu e no interior da "Casa Bomba" apreenderam mais drogas e a carteira de trabalho do réu, o que o vincula às mesmas.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, trazer consigo, ter em depósito e guardar, pelo que caracterizado o crime.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 24/26) e laudo definitivo (fls. 116/118).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 63/64 - proc. 187-56.2017 - em R.A - fls. 63; fls. 64 - proc. 2342-32.2017 - em R.A - fls. 63).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (fls. 22 - 506 porções de maconha, 883 invólucros de cocaína e 1119 pedras de "crack"), já que pequena quantidade em Diadema é inferior a 100 porções, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência e a confissão extrajudicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que ostenta duas condenações anteriores também por tráfico.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é duplamente reincidente específico (fls. 63/64 - proc. 187-56.2017 - em R.A - fls. 63; fls. 64 - proc. 2342-32.2017 - em R.A - fls. 63), o que denota personalidade voltada para a prática de crimes, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita, o que demonstra que o tráfico é seu meio de vida e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis", diante do montante da

pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 10.08.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 02.01.25).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da dupla reincidência específica (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO EVANDRO DE SOUSA SILVA à pena de 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que não há nada que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou ocupação lícita nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomenda-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto aos 4 (quatro) aparelhos de telefone celular apreendidos (fls. 21/22 - marca LG modelo LG-A275, marca Samsung modelo SM-A015M/DS, marca Samsung modelo não especificado e marca Asus modelo ZB57TL de cor azul), já periciados (fls. 119/121, 122/124, 125/126 e 163/164), não há provas nos autos de que eram utilizados ou são proveito do tráfico, pelo que oficie-se desde já informando que não interessam mais ao feito e que decorrido o prazo do art. 122 do CPP pode ser dado o destino pertinente.

Em relação ao cartão claro chip (sem o chip), às folhas de papel com anotações manuscritas apreendidas (fls. 21), já periciadas (fls. 127/129, 130/131 e 174/175), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada.

Quanto ao contrato de locação, à conta da ENEL em nome de José Belarmino Filho e à CTPS do réu, apreendidos (fls. 21), já periciados (fls. 132/134, 135/136 e 172/173), oficie-se, desde logo, informando que não interessa mais ao feito e que podem ser entregues aos mesmos.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 77) e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 17 de novembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA